

1501748-65.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2225348/2022 - 3º Distrito

Policial de Diadema, FC9251/2022 - 3º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ PEDRO REBELLO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501748-65.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501748-65.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2225348/2022 - 3º Distrito

Policial de Diadema, FC9251/2022 - 3º Distrito Policial de Diadema

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI

Vistos,

LEANDRO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 14h30min, na Travessa Amazonas, altura do nº 50, Taboão, nesta cidade e comarca, o acusado tinha em depósito, para o consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 23 (vinte e três) porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 2,4g, 07 (sete) porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 6,2g, e 43 (quarenta e três) porções individualizadas de cannabis sativa L, com peso líquido total de 94,2g, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica. O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 132/134 .

O réu foi regularmente notificado (fls. 123), tendo apresentado defesa preliminar às fls. 127/128. A denúncia foi recebida às fls. 141/142, e o réu foi regularmente citado à fl. 178.

Na audiência de instrução debates e julgamento foi colhida a prova oral. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, nos termos do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, pelo mérito a presente ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 132/133, que atestou positivo para as substâncias entorpecentes tetrahydrocannabinol (THC – maconha) e cocaína, substâncias estas consideradas ilícitas pela Portaria 344/1998 SVS/MS. Consigno que a perícia não foi contestada pela defesa.

A autoria também restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelas provas colhidas durante a fase de investigação policial, quanto pelas provas produzidas em juízo.

É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Em juízo, a testemunha Marcelo Sartori Rosseto, policial civil, confirmou os fatos em que fundada a pretensão punitiva, esclarecendo inclusive que houve admissão por parte do réu em relação aos fatos. Não se lembra se era dia de operação.

A testemunha Rafael Rodrigues de Azevedo, igualmente policial civil, ouvido em juízo, prestou depoimento em sentido similar.

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo por estes policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu. E, afinal, o fato de estas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, sobretudo porque seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n.º 74.608-SP – STF).

Deve-se ressaltar que o réu, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, afirmou que estava traficando as drogas. Relatou que é morador de rua e estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos, sendo que o estojo localizado pelos policiais era de sua propriedade, local onde armazenava as drogas (fls. 20).

Em Juízo o acusado referiu que os fatos não condizem com a verdade, eis que se encontrava no local para usar drogas, mas não na condição de traficante. Foi abordado pelos policiais, e trazia drogas consigo, mas para uso próprio. Acredita que como era dia de operação acabou ficando detido especialmente por conta de seus antecedentes. Nega a traficância.

Sua versão não convence.

Ora, nos termos do art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso dos autos, o local em que ocorreu a prisão (conhecido ponto de tráfico de drogas), a forma como estava embalada a droga, a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, o encontro de dinheiro em espécie e o resultado da observação prévia feita pelos policiais são indicativos do intuito de traficância. Por outro lado, pela própria quantidade e demais circunstâncias, não há como desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, sendo certo que a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, podendo coexistirem pacificamente em uma única pessoa.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira "lei do silêncio", por temer sofrer represálias.

Neste contexto, a prova dos autos demonstra que os policiais civis, em diligências no local dos fatos, avistaram o acusado em movimentação indicativa do comércio ilícito, pois terceiros se aproximavam dele e lhe entregavam algo. Perceberam que o acusado dirigia-se a um veículo estacionado na via pública e retornava com algo que repassava àqueles transeuntes. Após ser constatada a típica movimentação de tráfico, o acusado foi abordado, com quem foi localizada a quantia de R\$ 15,00 em espécie, bem como embaixo de um automóvel próximo, onde o acusado pegava certos itens, encontraram um estojo com as mencionadas drogas.

Não há dúvidas de que o comportamento do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1.^a T. - HC n.º 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p. 11.012).

Destaco que não se trata de carimbar as versões policiais, mas sim de aquilatar a validade dos depoimentos policiais que podem em dadas situações, ausentes aqui no caso, revelarem-se inconsistentes e não fundamentarem um decreto condenatório.

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

"Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar e lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.^a Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

É o que basta para a caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Comprovada, assim, a autoria e a materialidade do delito. Impõe-se, nestes termos, a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, seguindo os critérios do art. 42, da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, deve ser considerada como circunstância judicial preponderante desfavorável a natureza das drogas apreendidas, dentre elas a cocaína, substância que notoriamente vulnera de forma mais intensa o bem jurídico protegido - qual seja, a saúde pública -, causando maior grau de dependência do que outras drogas ilícitas, como a maconha. Anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também

constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.^a ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286, grifei). Significa dizer que o legislador explicitou, no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que já deveriam ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59, do Código Penal, transformando-as em preponderantes.

Ademais, anote-se que o acusado ostenta algumas condenações definitivas, sem efeito de reincidência, porquanto já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos (processos n.º 0027974-20.2000.8.26.0161, 0012419-21.2004.8.26.0161, 0004651-68.2009.8.26.0161, 0012782-56.2014.8.26.0161 penas cumpridas, respectivamente, em 04/02/2004, 07/02/2008, 12/05/2014 e 20/05/2016, conforme fls. 60/72 e 168/174). Referidas condenações podem ser usadas para fins de reconhecimento de maus antecedentes. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG. 20-11-2020 PUBLIC. 23-11-2020, grifei).

Desta forma, a pena base deve ser agravada em 1/5, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo, considerando as condições econômicas do réu.

Na segunda fase da dosimetria, considero eficaz a confissão efetuada pelo réu (utilizada como fundamento para condenação, nos termos da Súmula n.º 545, do E. Superior Tribunal de Justiça). Em razão disso, aplico a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP e reduzo as penas em 1/6. Obtenho, assim, as penas de 5 anos de reclusão, e 500 dias multa, cada qual no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006. Isto porque, para incidência do referido dispositivo legal, é necessário o concurso simultâneo de quatro circunstâncias, quais sejam: (i) que o agente seja primário, (ii) de bons antecedentes, (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) nem integre organização criminosa. Ora, no caso dos autos, o réu ostenta maus antecedentes, bem como, inclusive, possui algumas condenações pelo crime de tráfico de drogas. Assim, torno definitiva a pena supracitada, de 5 anos de reclusão, e 500 dias multa.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do habeas corpus n.º 111.840-ES (Informativo STF n.º 507), ser inconstitucional a fixação obrigatória de regime inicial fechado, consoante dispõe o § 1.º, art. 2.º, da Lei n.º 8.072/90, com as alterações decorrentes da Lei n.º 11.464/07. Assim, de acordo com referido precedente, compete ao juiz, analisadas as especificidades do caso concreto, fixar o regime inicial de cumprimento de acordo com as disposições do art. 33, do Código Penal.

Este mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela, quer pela chamada

"objetivação do controle difuso" (tese adotada e aplicada pelo E. Supremo Tribunal Federal), quer em sede de controle difuso de constitucionalidade por este Magistrado, declarando-se a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do dispositivo legal em comento. De fato, a fixação a priori, pelo legislador, de um regime inicial de cumprimento, sem permitir que o Magistrado possa aferir, no caso concreto, qual o regime mais adequado para o sentenciado, com análise dos requisitos objetivos e subjetivos, fere o princípio implícito da proporcionalidade e o princípio da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5.º da CF/88). Partindo destas premissas, passo a fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando a quantidade de pena estabelecida e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (consoante fundamentação acima), o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, observados os termos do art. 33, § 3.º, do CP. Consigno que à vista das especificidades do caso concreto, considerando a diversidade das drogas e a traficância de substâncias que causam uma maior dependência química, a fixação de regime inicial diverso não seria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta. Ademais, a fixação deste regime inicial não fere o disposto no art. 33, § 3.º, que estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal. Ocorre que conforme fundamentação acima, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de estarem evidenciadas no art. 42, da Lei n.º 11.343/2006 como preponderantes, também são circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59, do Código Penal. No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, verifico que diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso, ainda que considerado o tempo da prisão preventiva. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei).

De fato, raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o juízo das execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

Em que pese os termos da Resolução n.º 05, do Senado Federal, não estão presentes os requisitos autorizadores à substituição da pena por restritiva de direitos, notadamente pela quantidade de pena estabelecida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar LEANDRO FERREIRA DA SILVA qualificado nos autos, à pena 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006

Mantenho a prisão preventiva do acusado. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Por tal razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos das decisões proferidas nestes autos, adotando-as como razão de decidir. Expeça-se mandado de prisão, de acordo com as NSCGJ, se necessário.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, na forma do artigo 4.º, § 9.º, da Lei 11.608/03, contudo, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiário da Assistência Judiciária. Assim, fica dispensada a intimação do condenado para

pagamento da taxa judiciária.

Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006.

Decreto a perda dos valores apreendidos, conforme auto de exibição de apreensão de fls. 11, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado:

a) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

Não havendo interesse na preservação do estojo apreendido (auto de apreensão de fl. 11), e considerando a ausência de valor econômico, autorizo sua destruição.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Expeça-se o necessário.

Diadema, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA